

1501670-56.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/05/2022

... acusado do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os policiais militares Diego José Ribeiro Ferreira e Diego Lopes Vieira dos Santos narraram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos - já conhecido pela prática de tráfico de drogas - quando se depararam com um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1501670-56.2021.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501670-56.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Emerson de Moura Andrade

Réu Preso

Vistos.

Emerson de Moura Andrade foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 08 de dezembro de 2021, por volta de 10h, na Rua São Caetano nº 300, bairro Imaculada Conceição, nesta cidade e comarca de Taubaté, adquiriu e guardava, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, uma porção pesando cerca de 155,66g de cocaína, na forma de crack, bem como recebeu e tinha em depósito cinco munições calibre 38", de uso permitido, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Descreve a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando se depararam com o réu em cima do telhado de uma construção, em atitude suspeita, pois carregava uma sacola. O réu foi abordado e verificou-se que no interior da sacola que portava havia cápsulas plásticas vazias, comumente utilizadas na embalagem de drogas. Indagado, o réu afirmou que participava da venda de drogas no local e seria o responsável pela distribuição de cápsulas para embalagem de drogas e pelo recolhimento do dinheiro obtido com sua venda. Com autorização do réu os policiais adentraram no imóvel de onde ele havia saído. No local encontraram uma caixa de papelão, em cujo interior havia um aparelho celular, uma balança de precisão, um

caderno com anotações do tráfico ilícito, sacolas plásticas contendo mais cápsulas plásticas, R\$ 2.760,00 em dinheiro, uma porção de crack pesando cerca de 155,66g e cinco munições intactas de calibre 38" (fls. 80/82).

Recebida a denúncia, em 17 de dezembro de 2021 (fls. 86/89), antes mesmo de ser citado (fls. 117) o réu apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 93/96).

Saneado o processo, e indeferidos os requerimentos defensivos de rejeição da denúncia (fls. 109/112) e de requisição à Polícia Militar de relatório de rastreamento de GPS das viaturas empregadas na prisão do réu, porquanto providência extemporânea e irrelevante (fls. 150/151), realizou-se audiência de instrução por teleconferência, mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 158/159), oportunidade em que se procedeu à inquirição das testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa, e ao interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, em que postulou a condenação do réu nos termos da denúncia, por não comprovada sua alegação de que o flagrante foi forjado, a qual restou isolada frente às demais provas produzidas. Requereu a fixação das penas-base acima dos mínimos legais para ambos os delitos em razão dos maus antecedentes do réu, da quantidade de substância apreendida, que renderia quase quinhentas porções de crack aptas à venda a terceiros, e do maior poder vulnerante dessa substância; o reconhecimento da reincidência, impeditiva da aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; a soma das penas ante o concurso material de crimes; a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, o perdimento do valor apreendido em favor da União e a destruição das drogas, petrechos e munições apreendidos.

Em memoriais escritos a defesa pugnou pela absolvição do réu quanto a ambos os crimes, pautando-se nas alegações de que a posse de munições é fato atípico e de que não há provas suficientes de que a droga apreendida fosse de propriedade do réu ou de que ele a estivesse armazenando; haver divergências nas declarações dos policiais acerca de quem seria a pessoa que estava no telhado; faltar prova pericial a respeito da caligrafia no caderno de anotações. Para a hipótese de condenação, requereu seja a conduta de posse de munições incursionada no art. 12 da Lei nº 10.826/03, e não no art. 14 do mesmo dispositivo legal. Já em relação ao crime de tráfico de drogas, pleiteou a fixação das penas-base no mínimo legal; a observância do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com aplicação do redutor máximo da pena ou pela metade, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 167/171 e documentos de fls. 172/173).

Por fim, assentou-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 174/175).

É o relatório.
Decido.

O réu está sendo acusado do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os policiais militares Diego José Ribeiro Ferreira e Diego Lopes Vieira dos Santos narraram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos – já conhecido pela prática de tráfico de drogas – quando se depararam com um indivíduo em cima do telhado de uma construção. Quando adentraram em uma viela para averiguar do que se tratava, visualizaram o réu carregando consigo uma sacola plástica, que verificaram conter cápsulas plásticas

vazias comumente utilizadas para acondicionar entorpecentes. Abordado e inquirido, o réu confessou que participava do tráfico de drogas e que sua função era fazer a distribuição dessas cápsulas plásticas, bem como recolher o dinheiro do tráfico e repassá-lo ao seu chefe, cujo nome não declinou. Na companhia do réu e mediante sua autorização adentraram no imóvel do qual ele havia saído, onde localizaram uma caixa de papelão em cujo interior havia um aparelho de telefone celular, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico de drogas, valor em espécie, uma porção de crack, sacolas plásticas contendo cápsulas plásticas vazias comumente utilizadas para acondicionar entorpecentes e munições intactas de calibre .38 (fls. 09 e 10, respectivamente).

Também em juízo os mesmos policiais declararam que durante deslocamento passaram por local já conhecido pelo tráfico de drogas e se depararam com um indivíduo em cima do telhado de um imóvel em construção, ao lado da casa do réu. Quando foram averiguar a situação, depararam-se com o réu saindo de uma casa, com uma sacola em mãos, o que gerou suspeita. Abordado o réu, verificaram que na sacola que portava havia vários eppendorfs vazios. Indagado, o réu confessou o envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou ser responsável por preencher e distribuir os pinos e recolher o dinheiro obtido com a venda de drogas, utilizando o imóvel para esse fim. O réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel do qual havia saído. Era um lugar pequeno, onde havia uma caixa grande com muitos eppendorfs vazios (cerca de 50 mil, segundo o PM Lopes), elevada quantia de numerário, uma pedra bruta de crack, um aparelho celular de propriedade do réu, caderno com anotações do tráfico e munições de calibre .38, além de balança de precisão, segundo o PM Ribeiro. Porque o réu não portava documentos, foram apanhá-los na casa da mãe e do irmão do réu antes de conduzi-lo à delegacia, não tendo realizado vistoria nesse local. Não conheciam o réu antes dos fatos.

O réu negou as práticas delitivas em ambas as ocasiões em que interrogado.

À autoridade policial afirmou que o local em que reside é um cortiço onde há quatro casinhas e os moradores entram e saem continuamente, deixando os imóveis normalmente abertos. Estava dormindo quando foi surpreendido pela presença de policiais militares no interior do seu imóvel, os quais lhe apresentaram o material apreendido: um telefone celular, valores em espécie, uma balança de precisão, um caderno com anotações diversas, munições de calibre 38, uma porção de crack e cápsulas plásticas comumente utilizadas para acondicionar entorpecentes. Negou aos policiais que fosse o proprietário daquele material, com exceção do telefone celular, que lhe pertencia e foi apreendido em sua posse quando acordou com a entrada dos policiais no imóvel. Em razão do fluxo intenso de pessoas no cortiço, acredita que esse material lá foi deixado e encontrado pelos policiais. Permanecia esporadicamente nesse imóvel, pois reside na casa de sua mãe, na Rua Marina Castilho de Oliveira Costa nº 260, bairro Parque Piratininga, onde ficam suas roupas e documentos, para onde os policiais se dirigiram em sua companhia e onde nada de ilícito foi encontrado. Lá, pegaram seus documentos pessoais – identidade e CNH – que foram devolvidos ao seu defensor. Já foi preso e processado anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (fls. 11).

Em juízo disse que foi acordado por volta de 8h30min com a invasão dos policiais militares à sua residência. Eles ingressaram no seu imóvel achando que alguém lá havia se escondido. Reside num cortiço, onde o portão é aberto e único, havendo várias pessoas que entram e saem. O local é um corredor com 4 imóveis, e todos possuem portão e rancho. Onde ele estava também havia a porta da cozinha, que estava encostada. No imóvel havia objetos pessoais como roupas e a sua CNH, pois trabalha como motoboy. Acredita que a caixa de objetos foi abandonada por alguém, mas nada viu por que estava adormecido. Em relação aos objetos apreendidos, somente o celular era de sua propriedade. Na ocasião, apresentou a CNH e disse que tinha passagem por tráfico de drogas e porte de armas. Os policiais foram até a casa de sua mãe para pegar outro documento com o fim de confirmar a sua identidade, pois na

sua CNH faltavam dois dígitos do RG. Durante o deslocamento com a viatura, os policiais pararam com ele na mesma rua – São Caetano –, em frente à escola Monte Belo, onde permaneceram por cinco ou dez minutos. Já na casa de sua mãe, reviraram o local e nada foi encontrado. Pegaram a sua carteira de trabalho e deslocaram-se à delegacia. Perto do Taubaté Shopping voltaram para o bairro Vila Velha e pararam num terreno com construções abandonadas. Nesse local, os policiais começaram a indagá-lo sobre o esquema de tráfico de drogas. Desconhecia quem seria envolvido com o tráfico de drogas e nada confessou. Respondeu que residia na casa de sua mãe, porém, sofreu um acidente há um ano e estava se recuperando. Como possui um irmão que é dependente químico (usuário de crack), pernoitava naquele lugar alugado por sua mãe para que não passasse por estresse, mas permanecia durante o dia na casa de sua mãe, recebendo seus cuidados. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

A narrativa do réu, além de inverossímil, restou não só improvada, como também contrariada pelas demais provas produzidas.

Restou incontroverso que o réu habitava uma residência multifamiliar, que ele próprio denominou de cortiço e descreveu como sendo um corredor com quatro imóveis, cada qual com seu portão. Também o PM Lopes descreveu que o local em que se deu a abordagem trata-se de um imóvel em que há um muro à direita e vários quartos à esquerda, um ao lado do outro, que são locados a terceiros.

O réu disse ter sido surpreendido com a presença dos policiais no interior de sua casa, quando ainda estava dormindo. Em juízo até buscou justificar a conduta dos policiais, sustentando que assim teriam agido porque acreditavam que uma pessoa poderia ter ali se escondido. Porém, em ambas as oportunidades em que interrogado alegou que o material apreendido pelos policiais lhe foi apresentado sem que saiba onde foi encontrado, alegando que a caixa contendo os objetos poderia ter sido abandonada por terceira pessoa no local, já que há fluxo intenso de pessoas no cortiço. Contraditoriamente, após negar a posse e propriedade de todos os objetos ilícitos, confirmou que o celular igualmente apreendido lhe pertencia.

Diversamente, entretanto, ambos os policiais afirmaram ter visualizado o réu saindo de um desses cômodos que compõem o imóvel. Abordaram-no porque já estavam diante da conduta suspeita de outro rapaz que estava sobre o telhado, o que foram averiguar, e se depararam com o réu na posse de uma sacola, em local conhecido como região de tráfico de drogas. Na sacola havia vários pinos vazios, que o réu confidenciou ser sua função preencher com drogas e distribuir.

O imóvel de que o réu saiu foi identificado. O PM Lopes assinalou ser o segundo dos quartos ali existentes, a partir da rua.

Ilson Celestino da Silva, proprietário do imóvel, que o descreveu como composto por quatro pequenos cômodos, em declaração escrita, por ele assinada, confirmou ter alugado ao réu o segundo deles “para quem entra no imóvel” (fls. 147).

Trata-se, portanto, de um cômodo perfeitamente individualizado, ainda que não ostente numeração.

De acordo com os policiais, especificamente no cômodo que o réu habitava havia objetos pessoais a ele pertencentes, como celular, capacete, perfume, tênis e roupas. No mesmo ambiente estava a caixa contendo os materiais ilícitos. O PM Lopes descreveu, ainda, que o réu havia colocado objetos pessoais sobre a referida caixa, o que rechaça a possibilidade de que houvesse sido deixada no local por terceiros, como buscou sustentar o réu, notadamente em se considerando que continha mais de dois mil e setecentos reais, que por certo não seriam abandonados.

Os policiais assinalaram que não realizaram buscas nos demais cômodos do imóvel, e para essa atitude não haveria motivação, já que se tratava de locações de

terceiros, que não guardavam qualquer relação com o réu. Portanto, a caixa estava, inequivocamente, no cômodo locado pelo réu, e a ele pertencia, assim como seu conteúdo.

Ilson declarou, ainda, que o réu estava em seu cômodo quando a polícia o prendeu, não o tendo visualizado em cima do telhado. De fato, em nenhum momento os policiais afirmaram que o indivíduo que estava em cima do telhado era o réu. Pelo contrário, ambos assinalaram que o réu foi visualizado saindo de um dos cômodos do imóvel e que não acreditavam que se tratava da pessoa que estava sobre o telhado, a qual acabou não sendo abordada.

De todo modo, mesmo não sendo o réu a pessoa visualizada sobre o telhado do imóvel vizinho, os policiais não invadiram sua casa, nem o surpreenderam enquanto dormia, e nem razão alguma teriam para fazê-lo, já que não o conheciam e nada sabiam de específico ao seu respeito ou sobre sua moradia. Os policiais apenas ingressaram na casa após autorizados pelo próprio réu e no local, conforme descreveram, realizaram vistoria e encontraram a caixa com os objetos ilícitos.

Os policiais descreveram que o réu adotou atitude colaborativa, permitindo a entrada e as buscas em sua casa; assumiu a responsabilidade por todo o material apreendido e confessou informalmente a prática do tráfico. O PM Lopes asseverou, ainda, que o réu afirmou morar em outro bairro e que havia locado aquele imóvel há pouco tempo, a fim de armazenar drogas no local.

Os policiais, que não conheciam o réu anteriormente, não teriam razão para narrar condutas que o réu não houvesse adotado.

Sequer retira a credibilidade da conduta e dos depoimentos dos policiais o fato de não terem apontado testemunha civil presencial à abordagem. Ademais, a defesa bem poderia ter encetado diligências para identificar eventuais civis que houvessem testemunhado a abordagem policial, a fim de trazê-las a juízo, mas embora com oportunidade, quedou-se inerte.

Os policiais são investidos de função pública e habilitados ao mister a que se dedicam e não há razão para duvidar-se de seu proceder se não há causa válida de suspeição.

A respeito, o voto do Eminentíssimo Desembargador Edison Brandão (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal) esgota a abordagem da questão:

“Note-se que o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela.

As falas destes profissionais possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque não restou provada qualquer intenção dos servidores em, de alguma forma, prejudicar a ré, pessoa que sequer conheciam.

No mais, não se pode desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

(...).

Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções. Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas testemunhas são os próprios condutores, responsáveis pela prisão em flagrante? (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0027037-56.2017.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

Nesse contexto, perde relevo a alegação do réu de que não confessou aos policiais a posse dos materiais ilícitos e seu envolvimento com o tráfico, havendo verossimilhança na assertiva de que locou o imóvel com o propósito de armazenar drogas no local, além de ali pernoitar, ainda que residisse de forma mais habitual com sua mãe.

Os materiais ilícitos pertenciam ao réu e é inequívoca sua destinação ao tráfico de drogas, posto que apreendida uma pedra grande de crack, balança de precisão, caderno com anotações típicas do tráfico, inúmeros eppendorfs vazios, usualmente utilizados para armazenar drogas, e elevada quantia de numerário em espécie. Ademais, o réu foi surpreendido quando saía de sua casa na posse de uma sacola contendo eppendorfs vazios, cuja distribuição enalteceu ser uma de suas funções.

Comprovada a autoria delitiva, resta salientar que a respeito da conduta foram lavrados Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/03) e Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), registrando-se a apreensão, em poder do réu, em sacolas plásticas, de um aparelho celular Motorola E7; uma balança de precisão; um caderno com anotações; 24 (vinte e quatro) pacotes plásticos fechados, contendo cada um a quantidade de 1.000 (um mil) eppendorfs; a quantia de R\$2.760,00 em dinheiro e uma pedra de crack (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 07/08).

Tanto preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 16/18), como definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 138/140), identificou-se que a droga apreendida em poder do réu, com massa líquida total de 142,77g, tratava-se, efetivamente, de cocaína, pois "foi DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, que se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)".

Outrossim, periciados os cinco cartuchos de munição cal.38 spl da marca CBC, todos íntegros, igualmente apreendidos na posse do réu, constatou-se sua eficácia positiva (Laudo Pericial de Peças a fls. 141/144).

Está bem provada, portanto, também a materialidade de ambos os delitos. Apenas comporta correção a imputação de incursão no art. 14 da Lei nº 10.826/03: conquanto a posse de munições seja conduta tipificada como delituosa e comporte sancionamento, não se evidenciou de que forma o réu teria recebido os cartuchos, havendo prova, por outro lado, de que os mantinha consigo no interior de residência, ainda que não fosse sua moradia habitual. Nesse contexto, a conduta comporta melhor adequação ao disposto no art. 12 da mesma lei, conforme pleiteia, ainda que subsidiariamente, a defesa técnica do réu.

Procede-se à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

tráfico de drogas

O réu estava em poder de mais de 140g de crack, substância entorpecente cujos efeitos deletérios sobre o organismo humano são muito mais drásticos que o de outras substâncias de uso proscrito no Brasil, sendo mais grave, portanto, a potencialidade lesiva de sua conduta, porque agravado o risco à saúde pública, dada a probabilidade de disseminação da droga entre seus consumidores, o que evidentemente ocorreria, caso o intento delitivo não fosse obstado pela ação policial. Não bastasse, possuía petrechos destinados ao fracionamento e acondicionamento de drogas em embalagens unitárias, havendo consigo quase 25.000 eppendorfs vazios, quantidade que em muita extrapola o ordinário.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, à vista da

preponderância do caráter de maior lesividade da conduta, fixo as penas-base um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A Folha de Antecedentes (fls. 51/59) e a Certidão de Distribuições Criminais (fls. 47/50) relacionadas ao réu apontam que ele registra condenações por tráfico de drogas nos autos nº 0016044-48.2012.8.26.0625 (da 1ª Vara Criminal de Taubaté), com trânsito em julgado em julho de 2013, e por desacato nos autos nº 0006332-41.2011.8.26.0634 (do Juizado Especial Cível e Criminal de Tremembé), com trânsito em julgado em setembro de 2012, e as penas impostas nessas ações penais foram julgadas extintas em março de 2019. Portanto, deve incidir a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63).

Por outro lado, ainda que o réu tenha se retratado em juízo, aos policiais militares, durante a abordagem, confessou seu envolvimento com o tráfico e inclusive apontou as funções que exercia, o que deve importar no reconhecimento da atenuante da confissão (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois constituiu elemento de convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).

Deve ser aplicado à hipótese o entendimento do STJ a respeito da questão, firmado em julgamento de tese sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585).

Contudo, o mesmo Tribunal ressalva que, nos casos em que a reincidência é múltipla ou específica – como na hipótese –, prepondera a circunstância agravante, operando-se, nessa hipótese, compensação meramente proporcional.

“O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente ou com reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (HC 345.398-DF, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 02.06.2016, DJe 10.06.2016). Grifou-se.

Portanto, reconhecidas ambas as circunstâncias, devem ser compensadas entre si no que atine a uma das reincidências, remanescendo outra que importa no recrudesimento das penas em um sexto, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

A múltipla reincidência do réu impede, objetivamente, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à hipótese.

Não havendo nos autos informes sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), o valor unitário do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião de acordo com os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

posse de munições

A respeito dessa conduta - observada sua incursão no art. 12 da Lei nº 10.826/03 - não são desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal: sua culpabilidade não destoa do ordinário de condutas similares, nem se afiguram excepcionais as circunstâncias ou as consequências do delito, o que conduz à fixação das penas-base em seus mínimos legais, de 1 ano de detenção e 10

dias-multa.

O réu não confessou em específico a posse das munições, sequer forneceu alguma explicação para sua existência em meio aos seus pertences, mesmo que durante sua abordagem, não incidindo, em consequência, a atenuante da confissão em relação a essa conduta criminosa.

Presente a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63), como já referido, múltipla e específica, elevo as penas de um quinto, a 1 ano, 2 meses e 12 dias de detenção e 12 dias-multa.

Não há causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição das penas a considerar.

Também em relação a esse crime fixa-se o valor do dia-multa no piso legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, a ser atualizado monetariamente desde essa ocasião segundo os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Em se tratando, na hipótese, de concurso material de crimes apenados com penas privativas de liberdade de espécies distintas - reclusão e detenção -, não devem estas ser somadas para fins de definição do regime prisional inicial, como se infere da dicção dos artigos 69 e 76 do Código Penal e art. 681 do Código de Processo Penal. Outrossim, a pena de reclusão deve ser executada por primeiro.

Não se olvide que eventual imposição de regime prisional inicialmente fechado para cumprimento de pena de detenção encontra óbice no caput do art. 33 do Código Penal, segunda parte, o qual apenas permite o regime fechado para a pena de detenção em caso de necessidade de transferência ao regime mais gravoso.

A respeito da questão, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “104. Aplicação cumulativa de reclusão e detenção: determina o art. 69, caput, parte final, que a reclusão seja cumprida em primeiro lugar. A inutilidade dessa disposição é evidente, na medida em que não existe diferença, na prática, entre reclusão e detenção. Na mesma ótica, confira-se a lição de PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR: “Em realidade, todavia, a disposição é inútil, pois as diferenças outrora existentes, entre reclusão e detenção, foram praticamente abolidas” (Comentários ao Código Penal, p. 238). E também: “Na verdade, o que houve foi excesso de zelo, pois, em termos práticos, de acordo com o nosso sistema, não se vislumbra diferença entre uma e outra” (WALTER VIEIRA DO NASCIMENTO, A embriaguez e outras questões penais (doutrina - legislação - jurisprudência), p. 90). O que importa para o condenado, na realidade, é o regime no qual foi inserido (sobre isso, consultar a nota 10-A ao art. 33). Portanto, quando o julgador aplicar o concurso material, fixando, por exemplo, três anos de reclusão e dois anos de detenção, não pode fazer o somatório em cinco anos pela diversidade de espécies de penas privativas de liberdade. Para a fixação do regime e demais benefícios, especialmente quando se cuidar de delitos dolosos, revendo nossa anterior posição, o juiz deve fixar o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção. Quando o sentenciado estiver cumprindo a reclusão no semiaberto (por progressão), ali começará a cumprir a detenção na sequência. Não é aplicável pena alternativa, cujo limite é de quatro anos (art. 44, I, CP), pois a pena privativa de liberdade, no total, superou quatro anos. Assim: TJMG: “Em se fazendo presente o concurso material de crimes punidos com regimes diferentes, leia-se reclusão e detenção, devem ser fixados regimes iniciais de cumprimento das sanções de formas separadas e dado o início do cumprimento pelo mais grave, na forma do art. 69, parte final, do Código Penal” (Ap. Crim. 1.0685.14.001171-7/001-MG, 7.a C. Crim., rel. Sálvio Chaves, 11.06.2015) (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado/Guilherme de Souza Nucci - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020). Grifei.

Com esses fundamentos, reconhecida a reincidência específica do réu e tendo em conta, no que atine ao crime de tráfico de drogas, a quantidade de pena imposta, fixa-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, não sendo obstatante a essa conclusão a análise da detração da pena (Código de Processo Penal, art. 387, § 2º).

Para o crime de posse de munições, em razão da espécie da pena privativa de liberdade e sua extensão, mas tendo em conta a múltipla reincidência, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena (a contrário senso do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal).

A quantidade de pena imposta e a reincidência específica do réu impedem, objetivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (Código Penal, art. 44, inc. II e § 3º, e art. 69, § 1º).

Como efeito automático desta sentença condenatória determino a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido em poder do réu, que não se comprovou tenha origem lícita, devendo ser considerado produto do narcotráfico (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva:

i) condeno Emerson de Moura Andrade à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 680 dias-multa, com cálculo unitário no piso legal, por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e

ii) devendo ser atribuída definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia, desclassifico a conduta inicialmente incursionada no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e o condeno à pena privativa de liberdade de 1 ano, 2 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 12 dias-multa, com cálculo unitário no piso legal, por incursão no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

O réu foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo, remanescendo inalteradas as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Está sendo condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade de considerável extensão, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, havendo fundado temor de que busque eximir-se de sua responsabilização caso seja colocado em liberdade neste momento processual.

Não se mostrando adequada, nem suficiente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determino a manutenção da medida constritiva de liberdade que anteriormente lhe foi imposta.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, oficiando-se.

Ao trânsito em julgado, além das providências de praxe, oficie-se à Senad encaminhando-lhe informação sobre o valor de R\$2.760,00, declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do auto de fls. 07/08.

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 15 de maio de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA